

1501048-45.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1501048-45.2020.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501048-45.2020.8.26.0542

Controle: 2020/001160

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Guilherme Henrique do Nascimento Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 14 de abril de 2020, por volta das 9h20min, na Rua Maria de Lurdes Galvão de França, 645, Padroeira, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, transportava 250 invólucros plásticos contendo 545,8g de maconha, substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, Guilherme Henrique, para realizar o transporte da droga acima descrita, solicitou corrida via aplicativo Uber, sendo atendido pelo motorista Antônio Ribeiro dos Santos, que conduzia o veículo General Motors Prisma, FKI-5164.

Ocorre que no trajeto, na altura do local dos fatos, cruzaram com uma viatura da Polícia Militar. Guilherme Henrique, que se sentava no banco traseiro, tentou se abaixar, escondendo-se.

Tal fato causou estranhamento na guarnição, que deu sinal de parada e foi prontamente obedecida pelo motorista.

Em revista pessoal, foi localizada com Guilherme Henrique uma sacola plástica com a droga.

Indagado, ele confirmou, informalmente, a autoria delitiva, dizendo aos milicianos que receberia R\$ 150,00 para transportar a droga até a biqueira. O motorista

Antônio, por sua vez, alegou que não tinha conhecimento que Guilherme Henrique levava entorpecente no carro.

A denúncia foi ofertada e notificado Guilherme Henrique por edital (fls. 99).

Sobreveio a defesa preliminar (fls. 109/118) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 8 de março de 2021 (fls. 126/127).

Considerando a não-localização de Guilherme Henrique, o processo-crime e o curso do prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 120/121).

O E. Tribunal de Justiça, em apreciação a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva de Guilherme Henrique (fls. 162/167). Posteriormente, cumprida a ordem de prisão, foi Guilherme Henrique pessoalmente notificado (fls. 210), levantando-se a suspensão processual (fls. 212/213). Guilherme Henrique foi citado (fls. 236).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 268/269). Houve desistência da oitiva de testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 271), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 270).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 271).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Guilherme Henrique nos termos da denúncia (fls. 274/277).

A Defesa pugnou pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e reconhecimento de incidência do artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal (fls. 288/295).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 63/65), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 237/238) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria (fls. 270).

Perante a D. Autoridade Policial, Guilherme Henrique se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 11).

Em Juízo, confessou a prática delitiva. Declarou que estava passando dificuldade financeira e morando de aluguel com amigo, quando recebeu a proposta para levar a droga e agiu por emoção e impulso. A polícia parou o motorista de aplicativo e fez a revista, sendo que o interrogando estava com a sacola de drogas. Não reagiu e assumiu as drogas. Essa foi a primeira vez que se envolveu no crime e está arrependido (fls. 270).

Inferir-se que a confissão representa idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas, inclusive pela confissão extrajudicial de autoria. Deve, pois, ser considerada sincera. Neste sentido:

"Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa". (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

Houve apenas alegação genérica do estado de necessidade, sem que fosse trazida qualquer prova aos autos, sendo inaplicável, portanto, o artigo 24, do Código Penal.

A testemunha Policial Militar Lucas afirmou que, em patrulhamento na região avistaram um Uber passando e o acusado, que estava no banco de trás, demonstrou nervosismo com a viatura. Fizeram abordagem e o acusado estava nervoso. Havia cheiro forte de droga. Na sacola que ele tinha foi apreendido entorpecente. Ele disse que ia receber dinheiro para deixar a droga na favela ali perto. Pegou os dados do motorista do Uber que compareceu à Delegacia para prestar

esclarecimento. Ele mostrou os relatórios da corrida que tinha feito no dia. Seu colega Lourenço está afastado porque fará uma cirurgia em razão de problemas na coluna. Apenas estavam os dois policiais na ocorrência (fls. 268).

A testemunha Policial Antônio asseverou que na época trabalhava com aplicativo e fez a corrida como qualquer outra. Não conhecia o acusado. Ele entrou no carro. O dia estava frio e chuvoso e estava com os vidros fechados. Quadras depois a polícia parou o veículo. Apresentou-se como motorista de aplicativo e apresentou o registro do aplicativo. Os policiais pegaram seus dados e liberaram. Três ou quatro horas após foi chamado para depor na Delegacia.

Não viu a droga ser apreendida. Não sabe dizer se era o acusado presente em audiência, pois ele estava de máscara, assim como o declarante (fls. 269).

O testemunho policial demonstra a veracidade dos fatos, até porque respondeu às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto no aspecto principal quanto no secundário, quer na fase extrajudicial como em Juízo.

Outrossim, corroboradas pela confissão judicial de Guilherme Henrique.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial” (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Guilherme Henrique. Ele estava no veículo da Uber, quando ao avistar a guarnição, tentou se esconder, ensejando sua abordagem. Com ele foi apreendido o entorpecente.

Informalmente e em Juízo, confessou a traficância.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Guilherme Henrique foi denunciado por transportar substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

“Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa”

(TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Guilherme Henrique por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso extrajudicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É primário e não ostenta maus-antecedentes criminais.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E

QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminoso ou à integração a organização criminoso. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente primário, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À míngua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da

Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto.

Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Considerando o quantum da reprimenda aplicada, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos levada a efeito, poderá Guilherme Henrique recorrer em liberdade. Observo que esta decisão, dada a alteração das circunstâncias fático-jurídicas, não afronta a decisão do E. Tribunal de Justiça, que decretou a prisão preventiva dele. Assim sendo, expeça-se, de imediato, o competente ALVARÁ de SOLTURA clausulado.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 06 de dezembro de 2022.